

1500728-06.2020.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... a analisar, separadamente, cada um dos delitos.

Tráfico de Drogas (Roberto e Eloá)

No tocante ao crime de tráfico de drogas imputado aos acusados, a ação é procedente, vez que, ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria deste crime narrado na denúncia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500728-06.2020.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500728-06.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2120715/2020 - DEL.POL.CLEMENTINA, 11438860 - DEL.POL.CLEMENTINA, 73/20/211 -

DEL.POL.CLEMENTINA, 73/2020 - DEL.POL.CLEMENTINA, 2120715 - DEL.POL.CLEMENTINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELOA CASSIA DO CARMO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1500728-06.2020.8.26.0603 (Controle nº 811/20).

VISTOS.

ROBERTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e ELOÁ CASSIA DO CARMO, qualificados nos autos, foram presos em flagrante, denunciados e viram-se processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e ROBERTO também no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 e ELOÁ no artigo 329, caput, do Código Penal, todos eles na forma do artigo 69, do Estatuto Penal.

Consta nos autos que ROBERTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e ELOÁ CASSIA DO CARMO, no dia 16 de maio de 2020, por volta das 14h, à Rua João Candido dos Santos, nº 103, Centro, na cidade de Clementina, nesta comarca de Birigui, guardavam 17 (dezessete) porções de maconha, 44 (quarenta e quatro) porções de crack e 31 (trinta e uma) porções de cocaína, substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos de constatação prévia de fls. 58/59, 60/61 e 62/63 e exames toxicológicos de fls. 257/259, 260/262, 263/265 e 266/268.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, ELOÁ CASSIA DO CARMO, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência aos policiais militares Mauro Américo Barbosa Moreira Sanchez e Michel Ricardo Gomes.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritos, ROBERTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA, possuía nas dependências de sua residência, 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida, municiado com 05 (cinco) cartuchos intactos, e acompanhado de outros quatro cartuchos também intactos, todos do mesmo calibre.

À acusada Luciene foi concedida liberdade provisória (fls. 124/126).

Recebida a denúncia em 15 de junho de 2020 (fls. 228/229), os acusados foram regularmente citados (fls. 225 e 350) e apresentaram defesas escritas às fls. 331/335 e 336/340.

Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 03 (três) testemunhas arroladas em comum (fls. 442/443), 02 (duas) testemunhas arroladas pela defesa da ré Eloá e 01 (uma) testemunha do réu Roberto, sobrevivendo, ao final, os interrogatórios dos acusados (fls. 530/531).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a parcial procedência da ação, absolvendo-se a ré Eloá e condenado o acusado Roberto, nos exatos termos da denúncia (fls. 534/547).

A defesa do réu Roberto pediu a sua absolvição. Preliminarmente, pugnou pela nulidade do processo, porque ocorreu invasão de domicílio e que as provas obtidas são ilícitas. No mérito, quanto ao tráfico de drogas, alegou insuficiência de provas, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Quanto ao crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, o acusado também deve ser absolvido, uma vez que a arma não lhe pertencia e foi encontrada em um terreno baldio. Em caso de condenação, requer a aplicação da pena no mínimo legal e a consequente redução (fls. 558/593).

Por sua vez, a defesa da ré Eloá pediu a improcedência da ação. Preliminarmente, pugnou pela nulidade do processo, porque ocorreu invasão de domicílio e que as provas obtidas são ilícitas. No mérito, quanto ao tráfico de drogas, alegou insuficiência de provas, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Quanto ao crime de resistência, a acusada também deve ser absolvida porque não há provas de que se opôs a execução de ato legal dos policiais. Em caso de condenação, requer a diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, com aplicação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e que seja concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 594/593).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos acusados pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº. 10.826/03) e resistência (artigo 329, do Código Penal). De início, a matéria arguida pela defesa, quanto à busca domiciliar na casa dos

acusados sem mandado judicial, fica rejeitada.

A matéria foi recentemente objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que cassou a decisão proferida anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça, cujas razões adoto, aqui, como razão de decidir, para afastamento dessa preliminar:

“De acordo com sólida orientação doutrinária e jurisprudencial há muito firmada, o tráfico de drogas é crime permanente, circunstância que autoriza o ingresso no imóvel residencial ou congêneres, em qualquer dia e horário, independentemente de mandado judicial, na formado disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A propósito: “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui delito permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, no caso, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Precedente.” (Superior Tribunal de Justiça, HC Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 11ª Câmara – Seção Criminal Apelação Criminal nº 1500279-55.2020.8.26.0439 - Pereira Barreto 5 451502/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). Em função disso, sempre que houver fundada suspeita da ocorrência do referido ilícito penal, não será possível falar em ilegalidade na ação dos agentes públicos, nem em ilicitude da prova amealhada, por inexistência de mandado de busca prévio ou específico, ou por estar caracterizada a invasão domiciliar. Afirmar-se o contrário implicaria prestigiar a atividade criminosa, em detrimento do trabalho policial realizado por agentes públicos regularmente investidos em suas funções, que ficariam inviabilizadas, com prejuízo irreparável para a sociedade. Imagine-se, por exemplo, que policiais estivessem realizando ronda rotineira, no exercício do policiamento preventivo e, ao passarem diante de uma residência qualquer, ouvissem gritos de socorro de uma mulher. A prevalecer o raciocínio segundo o qual o ingresso em residência só pode ocorrer quando houver segura conclusão acerca de crime em seu interior, mesmo diante da suspeitada ocorrência de violência doméstica, os agentes públicos estariam impossibilitados de intervir, e só poderiam ingressar na residência após a obtenção de ordem judicial, ou se a tanto autorizados pelo possível agressor, ou seja, quando o socorro à vítima já não seria mais útil. Tão absurda situação equivaleria à concessão de um passe livre para que residências servissem de palco para a prática dos mais diversos e graves delitos (homicídios, sequestros, lesões corporais, tráfico, estupro de vulneráveis, etc.), colocando a proteção às vítimas e da sociedade em patamar inferior aos direitos dos criminosos, e privilegiando a impunidade)... E nem se diga, por outro lado, que a diligência policial não foi devidamente documentada. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual se exigia documentação e registro audiovisual para o ingresso de policiais em residências (Habeas Corpus nº 598051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.342.077-SP, de que foi relator o Ministro Alexandre de Moraes, realizado no dia 02 de dezembro de 2021, ficando assentado que é “Incabível, portanto, na presente hipótese, em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias, para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE”. Enfim, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, nem é o caso de se determinar o desentranhamento de qualquer elemento probatório dos autos, já que todas as provas produzidas se afiguram válidas. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500279-55.2020.8.26.0439, Comarca de Pereira Barreto, 11ª Câmara de Direito Criminal, V.U., j. 03/02/22, rel. Des. XAVIER DE SOUZA).

Ultrapassada essa questão, pelo que se relatou na denúncia, a testemunha Maurício informou aos policiais de que os réus comercializavam entorpecentes, razão pela qual se dirigiram até a residência dos réus, no intuito de encontrarem as drogas, logo, houve situação que ensejava o estado de flagrância, justificador da entrada dos policiais.

Logo, evidente que houve situação que ensejava o estado de flagrância, justificador da entrada dos policiais, sendo dispensável qualquer ordem judicial. Ademais, embora a casa seja o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformada em garantia de impunidade de crimes que em seu interior se praticam. Assim, em se tratando de flagrante delito, não é necessário mandado de busca e apreensão domiciliar, pois o próprio texto constitucional admite que se penetre na casa mesmo à noite, e sem o consentimento do morador, no caso de flagrante delito, como foi o ora tratado.

Como se não bastasse, é cediço que, em se tratando de crime permanente, é dispensável qualquer exibição de mandado e também a presença de civis no local, até porque se sabe que, no mundo do tráfico, é comum as testemunhas não aparecerem para depor e são raras as pessoas que prestam depoimentos em juízo, tudo por receio de represálias e ameaças por parte dos traficantes. Desprezar, como regra, a ação dos policiais em caso como o dos autos, seria fechar os olhos para a nossa realidade, o que seria inadmissível.

Afastadas as preliminares, no mérito, a ação penal é totalmente procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos crimes narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Por se tratar de feito que envolve dois réus na prática de três crimes, passo a analisar, separadamente, cada um dos delitos.

Tráfico de Drogas (Roberto e Eloá)

No tocante ao crime de tráfico de drogas imputado aos acusados, a ação é procedente, vez que, ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria deste crime narrado na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); a nota de culpa (fls. 18 e 23); o boletim de ocorrência (fls. 10/14); o auto de apreensão e exibição (fls. 15/17); os laudos de constatação prévia (fls. 58/59, 60/61, 62/63 e 64/65); o relatório policial (fls. 217/219); os laudos periciais (fls. 158/164, 165/169, 170/178, 179/183, 184/206, 207/212), os laudos definitivos de exame toxicológicos (fls. 257/259, 260/262, 263/265 e 266/268); os depoimentos das testemunhas e as indigestas negativas trazidas pelos acusados, em ambas as fases da persecução penal.

A ré Eloá, na delegacia, disse que estava na sua residência e seu companheiro, Roberto, chegou e foi para o banheiro tomar banho, momento em que os policiais entraram na residência. Ficou muito nervosa, mas não tentou agredir os policiais, pelo contrário, alega que foi agredida por eles e levada para viatura. Nega ter recebido alguém na sua casa, disse que apenas uma pessoa foi lá para usarem drogas juntos. O crack encontrado é de Roberto porque ele é usuário do entorpecente. Não tinha conhecimento da quantidade de drogas localizadas no seu quarto e da arma. Nega a comercialização entorpecentes (fl. 08).

Em juízo, continuou a negar a prática criminosa. Disse que não autorizou a entrada dos policiais na sua casa e que não tentou agredi-los, porque eles entraram e já a algemaram. Afirmou que os policiais entraram e seu marido estava tomando banho, nu e mesmo assim algemaram. Não acompanhou as buscas dos policiais, mas viu que o policial Michel pulou o muro e voltou com uma sacola e colocou dentro da viatura. Narrou que na sua casa não tinha droga, apenas maconha que era para uso próprio, porém não tinha conhecimento se havia entorpecente dentro de casa, porque Roberto guardava dentro de uma pochete. Não sabia da existência da arma. Disse que no fundo

da casa há um terreno baldio abandonado. Roberto nunca vendeu drogas na sua casa. No dia dos fatos, não foi trabalhar porque ficou limpando sua casa (fls. 530/531). Por sua vez, o corréu Roberto, na delegacia, também negou a prática criminosa. Disse que, no dia dos fatos, havia acabado de chegar do serviço e estava tomando banho, quando policiais adentraram na sua casa e o algemaram. Em nenhum momento Eloá resistiu a prisão e ela foi algemada. Não acompanhou as buscas. Confirma que 13 porções encontradas em uma sacola eram de sua propriedade, porque é usuário de maconha. A pochete amarela e preta, com sedas e o valor de R\$ 1.469,00, dólar e moeda de coleção são seus também. Quanto às 04 porções grandes de maconha, 30 pinos de cocaína, 44 papелotes de crack e a arma não são de sua propriedade. A arma foi localizada em outro terreno, separado do muro. Afirmou que é usuário de maconha, juntamente com sua mulher, mas não de cocaína e crack. Negou ter fornecido maconha para alguém. Eloá é usuária de cocaína, mas a droga encontrada não é dela. Não sabe se alguém foi até sua casa usar maconha, porque estava trabalhando (fl. 09).

Em juízo, continuou a negar os fatos criminosos. Confirma a propriedade de 10 gramas de maconha que estavam com ele, e eram para uso próprio, uma vez que usa no seu trabalho na roça. As demais drogas localizadas não eram suas, bem como a arma de fogo. Eloá também é usuário de maconha, mas não vendem. O dinheiro apreendido era oriundo do seu trabalho e da venda de salgados e refrigerantes. Ninguém autorizou a entrada na residência e não acompanhou as buscas. Nunca traficou drogas, nem Eloá. No fundo da residência, no terreno vazio, havia usuários (fls. 530/531).

Como se vê o acusado Roberto assume a propriedade de parte da droga (10 gramas de maconha), no entanto, afirmou que era para uso próprio.

A negativa apresentada pelos acusados, quanto à traficância, está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtarem da responsabilização penal por conduta efetivamente praticada.

Com efeito, as testemunhas de acusação Mauro Americo Barbosa Moreira Sanchez e Michel Ricardo Gomes, policiais militares, ouvidos em ambas as fases, relataram que estavam em patrulhamento, quando avistaram Maurício saindo de uma residência, já conhecida nos meios policiais como ponto de tráfico. Abordaram-no e com ele localizaram uma porção de maconha, em um plástico branco, R\$ 140,00, um maço de papel de seda, utilizada para fazer cigarros e um celular. Questionado, informou que ganhou a porção do acusado Roberto e que lá teria grande quantidade de entorpecentes. Uma equipe foi até a casa de Roberto que, ao avistar os policiais, empreendeu fuga para o interior da residência, carregando em suas mãos uma sacola plástica branca. Ele tentou jogar a sacola no vaso sanitário, mas foi detido. Foi necessário usar de força física moderada para conter a ré Eloá, que tentava impedir a atuação dos policiais. Com Roberto encontraram a sacola com 13 porções de maconha, acondicionadas em embalagens semelhantes ao entorpecente encontrado com Maurício, além de R\$ 120,00 em notas diversas. Em vistoria na residência, acharam, embaixo da cama do casal, uma pochete com 01 porção de cocaína, 30 pinos de cocaína, 44 porções de crack, mais 04 porções maiores de maconha e R\$ 1.469,00 em dinheiro e moedas, inclusive de outro país, além de 15 maços de papel de seda, parecidos aos papéis encontrados com Maurício. No quintal da residência, do lado do muro dos fundos, escondido entre telhas, envolta em uma camiseta, localizaram um revólver Taurus, calibre 38, com numeração suprimida, municiado com 05 munições e 4 munições sobressalientes junto da arma. Também encontraram 03 celulares pertencentes aos réus. Eloá, ao ser conduzida para o veículo, novamente tentou agredir os policiais com chutes, sendo necessário uso de força física para contê-la. Havia um mandado de prisão em desfavor de Roberto (fls. 03/04, 05/06 e 442/443).

Em juízo, o policial Mauro afirmou que Roberto confessou o tráfico de drogas e Eloá também sabia do crime, tornando evidente que os dois trabalhavam juntos na comercialização dos entorpecentes. Sobre a arma, Roberto disse que era para sua defesa pessoal. Disse que havia diversas denúncias de prática de tráfico de drogas

pelos réus e que, quando Roberto não estava na residência, quem praticava o tráfico era Eloá. Eloá tentou impedir as diligências dos policiais, bem como a detenção do seu esposo. Os policiais não pediram permissão para adentrar na residência (fls. 442/443).

Por sua vez, o policial Michel afirmou que os acusados nada disseram sobre os fatos. Eloá tentou agredir os policiais e foi necessário uso de força para contê-la, empurrando a equipe policial. O réu Roberto falou que podia olhar a casa porque não havia nada de ilícito (fls. 442/443).

Como se vê, os policiais confirmaram a apreensão da droga e apetrechos na casa dos acusados, bem como da arma com numeração suprimida. Apesar de os policiais terem apresentado pequena contradição em seus depoimentos, isso não afeta, no substancial, a apuração da verdade, e devem ser consideradas como fruto da capacidade de observação de cada um, tratando-se de lapso corriqueiro na evocação da memória descritiva, não maculando o fato principal. Aliás, como tem reconhecido a jurisprudência, pequenas contradições demonstram que as testemunhas disseram a verdade e não montaram seus depoimentos. Logo, no caso concreto e levando em conta os demais elementos de prova existentes nestes autos, evidencia-se, com segurança, que os réus incidiram na prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Anoto que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicarem os acusados, ou em imputar falsamente a eles a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque eles não apontaram nada que justificasse essa circunstância.

A testemunha Maurício da Silva Vitor, na delegacia, disse que é usuário de drogas e sempre soube que Roberto vendia maconha, inclusive adquire entorpecentes dele, pagando R\$ 10,00 por uma porção de maconha. Trabalha junto com o Roberto na roça e ele vende as entorpecentes lá. Foi abordado pelos policiais que encontraram a porção de maconha dada por Roberto, para uso próprio. Viu que os policiais encontraram na casa de Roberto os entorpecentes e um revólver (fl. 07). Como se vê, esse depoimento está em total consonância com os relatos dos milicianos.

Posteriormente, compareceu na delegacia e, como sói de acontecer, alterou o depoimento, dizendo que ele e Roberto são usuários de maconha, mas nunca soube que ele vendia drogas (fl. 213).

Em juízo, afirmou que, quando foi abordado pelos policiais portava uma porção de maconha para uso próprio e que Roberto foi quem deu um pedacinho. Estavam na roça quando Roberto lhe deu um pedaço de droga. Nada disse aos policiais sobre Roberto ter drogas na residência. Nunca comprou entorpecentes de Roberto e nunca viu Roberto vendendo drogas na frente da sua residência. Afirmou que o primeiro depoimento que deu na delegacia estava sob efeito de drogas e foi pressionado e ameaçado pelos policiais. O dinheiro apreendido (R\$ 200,00) era oriundo do seu trabalho na roça, além do seu celular (fls. 442/443).

Esses depoimentos, se cotejados com os demais elementos de prova, inclusive com seu próprio depoimento dado na fase policial, não podem merecer a mesma credibilidade, uma vez que ficou demonstrado que a testemunha, na fase judicial, agiu com a intenção de afastar a responsabilidade do acusado, devendo prevalecer o primeiro depoimento prestado na fase inquisitorial e o que foi narrado aos policiais, quando da sua abordagem, no sentido de que havia comprado a droga do réu no local dos fatos, versão esta que se encontra em consonância com os demais elementos de prova colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

Aliás, neste ponto, anoto que tais alterações de depoimentos de testemunhas ouvidas

em processos de tráfico de drogas têm se tornado corriqueiras neste juízo, em outros casos semelhantes. Como é cediço, no mundo do tráfico, é comum as testemunhas não aparecerem para depor e são raras as pessoas que prestam depoimentos em juízo e, quando prestam, acabam alterando o que haviam dito na fase policial, no calor dos fatos, tudo por receio de represálias e ameaças por parte dos traficantes.

Desprezar esse relevante dado concreto em caso como o dos autos, seria fechar os olhos para a nossa realidade, o que seria inadmissível.

A testemunha de defesa da ré Eloá, Thais Leize Rossi, ouvida em juízo, disse que naquele dia, avistou um policial pular o muro dos fundos da casa e voltar com uma sacola e outro trouxe o réu Roberto algemado até a área da casa. Nunca viu Roberto traficando na roça (fls. 530/531).

A testemunha de defesa da ré Eloá, José Orlando Ferreira Santos, ouvida em juízo, afirmou que viu os policiais chegarem na casa dos acusados, pularem o muro e quebrarem tudo. Visualizou um policial pular o muro dos fundos e retornar com um saco preto. Confirmou que a casa existente no terreno do fundo é frequentada por usuários de drogas. Nunca viu Roberto vendendo entorpecentes na roça. Afirmou que, naquele dia, a única mulher que desceu no ponto foi Eloá, que também trabalhava na roça (fls. 530/531).

A testemunha de defesa do réu Roberto, Eliseu da Silva Gonçalves, ouvida em juízo, era quem contratava trabalhadores para as roças e, na data dos fatos, Roberto trabalhou até as três e meia da tarde. Confirmou que, naquele dia, fez o pagamento para o réu (fls. 530/531).

Essas testemunhas não têm o condão de afastar os depoimentos dos policiais e infirmar o restante do conjunto probatório.

Com efeito, seus depoimentos, se cotejados com os demais elementos de prova, não podem merecer a mesma credibilidade, uma vez que, ficou demonstrado que agiram na tentativa de afastar a responsabilidade do réu.

No que se refere aos entorpecentes, a perícia apontou que consistem realmente em "maconha" e "cocaína" (exames químico-toxicológico de fls. 257/259, 260/262, 263/265 e 266/268).

De outra parte, a grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, ou seja, 125,29 gramas de maconha e cocaína, as circunstâncias da abordagem dos réus (denúncia de tráfico de drogas); a forma de acondicionamento da droga (embalada em porções, prontas para comércio), o dinheiro apreendido, a apreensão de apetrechos (quatro celulares, duas pochetes, papel de seda), bem como da arma; estão a caracterizar a traficância.

No caso, não se pode olvidar que foram encontrados apetrechos (papel de seda) na casa do acusado, e este não apresentou qualquer justificativa plausível, o que só vem reforçar que ali se praticava o tráfico, haja vista que, como é cediço, apetrechos desse tipo são utilizadas para quantificação e preparo das porções que serão vendidas.

Outro ponto relevante de ser considerado é que, na casa do acusado, foi apreendida uma arma de fogo, o que só vem confirmar a prática do tráfico no local, porque, como é cediço, para a segurança do ponto de tráfico, delitos como porte de arma são praticados.

Oportuno frisar que, além dos entorpecentes mencionados, foram apreendidos grande quantia em dinheiro, além de três celulares, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/17, bens que, de costume, são deixados aos traficantes como garantia do pagamento dos entorpecentes adquiridos pelos usuários.

Quanto ao dinheiro apreendido, não obstante a testemunha Eliseu informar que, no dia dos fatos, pagou ao acusado Roberto, mais de R\$ 1.000,00, não foi apresentado qualquer documento comprovando o pagamento, ou a carteira de trabalho. Essa providência seria de fácil consecução, caso fosse verdadeira a narrativa apresentada em juízo. Ademais, não há como afirmar que o dinheiro apreendido era proveniente desse valor, uma vez que dinheiro é bem fungível, não se podendo afirmar que aquela quantia apreendida era mesmo relacionada ao pagamento do réu. Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a

consumação não exige qualquer resultado. No caso, os réus foram denunciados porque guardavam os entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Não se pode olvidar que o tipo penal do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 é chamado de tipo misto alternativo, possuindo vários núcleos, dentre eles, guardar entorpecente, conduta essa efetivamente praticada pelos acusados, mas que caracterizam crime único.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Portanto, a prova coletada nos autos é substancial e convincente, ficando evidente a autoria do crime por parte dos réus, no crime ora apurado. Lembre-se que, no caso, não se exige o chamado "dolo específico", mas apenas o dolo genérico, restando evidente que os acusados guardavam a droga descrita na denúncia para entrega a consumo de terceiros.

Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, os acusados guardavam 125,29 gramas de maconha e cocaína, substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros.

A conduta dos réus encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade. Neste ponto, embora os acusados tenham alegado que são usuários de drogas, tais alegações não restaram comprovadas, até porque a defesa não juntou quaisquer documentos, não requereu qualquer exame de dependência químico-toxicológico ou de insanidade mental. Ademais, os réus, em seus interrogatórios, demonstraram-se lúcidos.

Ressalto que, mesmo que se demonstrasse que o réu fosse usuário de drogas, isso, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas. Se o réu é viciado há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Diante desse quadro, a condição de ser o agente usuário não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem.

Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (Réu Roberto).

Quanto a esse delito, a ação também é procedente.

A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); nota de culpa (fl. 23); boletim de ocorrência (fls. 10/14); auto de exibição e apreensão (fls. 15/17); relatório final (fls. 217/219); laudo pericial de fls. 158/164; depoimentos das testemunhas e a indigesta negativa apresentada pelo acusado em ambas as fases da persecução penal.

Quer na fase policial, quer em juízo, o acusado negou a propriedade das armas (fls. 09 e 530/531).

Todavia, a negativa apresentada pelo acusado está totalmente contrária às provas coligadas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtar da responsabilização penal por conduta efetivamente praticada.

Os policiais militares Mauro e Michel, relataram que localizaram, no quintal,

enrolado em uma blusa, a arma de fogo. O réu negou a propriedade da arma (fls. 03/04, 05/06 e 442/443).

Em juízo, o policial Mauro disse que o réu afirmou que a arma era para sua defesa pessoal.

Reitero, aqui, os argumentos acima expostos sobre o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais.

A corré Eloá também disse desconhecer a existência de armas na residência (fls. 08 e 530/531).

As testemunhas Maurício, Thais, José Orlando e Elizeu nada mencionaram sobre a arma apreendida (fls. 07, 213, 442/443 e 530/531).

Por outro lado, o laudo pericial de fls. 158/164 confirmou que “a arma pode ser eficazmente utilizada para realização de disparo, uma vez que seus mecanismos estão aptos”; e a numeração estava suprimida “por forte desgaste do metal d sua área sede em virtude de aplicação de instrumento de abrasão”. Referente aos cartuchos, apurou-se que “0estavam aptos para realização de disparos”, o que basta para a tipificação do delito no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Diante desse quadro probatório, não há como se deixar de reconhecer que no dia, horário e local indicado na denúncia, o acusado ROBERTO possuía, nas dependências de sua residência, um revólver da marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida, e 09 (nove) cartuchos íntegros do mesmo calibre, todos eles sem autorização e em desacordo com determinação legal o regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência do delito definido no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade.

Resistência (ré Eloá).

No que se refere ao crime de resistência imputado à ré Eloá, a ação penal é procedente.

A acusada Eloá, na delegacia e em juízo, disse que ficou muito nervosa e assustada, mas negou ter investido contra os policiais. Afirmou que foi agredida por eles e levada para a viatura (fls. 08 e 530/531).

Em juízo, acrescentou que, por ser mulher, não teria força para agredir os policiais (fls. 530/531).

Contudo, a negativa de autoria trazida pela ré Eloá está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório.

O corréu Roberto, em ambas as fases, afirmou que sua esposa Eloá, em nenhum momento, resistiu à prisão (fl. 09).

Com efeito, as vítimas Mauro Américo Barbosa Moreira Sanches e Michel Ricardo Gomes, policiais militares, ouvidos tanto na fase policial, quanto em juízo, confirmaram que a ré Eloá resistiu à abordagem policial, tentando, a todo custo, impedir a ação policial, agredindo-os com socos e chutes, sendo necessário o uso de força física moderada para contê-la (fls. 04/05 e 227/vº).

As testemunhas Maurício, Thais, José Orlando e Elizeu nada mencionaram sobre a arma apreendida (fls. 07, 213, 442/443 e 530/531).

Como se viu, as vítimas foram unânimes em afirmar que a acusada Eloá resistiu à execução de ato legal, utilizando violência contra eles, necessitando que empregassem força física moderada para contê-la e uso de algemas. Presente, pois, o dolo específico de não permitir a realização de ato legal.

De outra parte, não há nos autos qualquer elemento de convicção a demonstrar que as vítimas teriam qualquer interesse em prejudicar a ré, imputando-lhe a prática de conduta definida como crime.

Relevante anotar que, embora em processos semelhantes (resistência em abordagem policial) tenha este Juízo decretado a absolvição do agente, tal fato se deu porque, naqueles casos, apesar de o réu ter se oposto à execução da prisão determinada pelo policial, em nenhum momento se valeu de violência ou ameaça aos policiais responsáveis pelo cumprimento da ordem judicial, e nenhum dos policiais

recebeu ameaças ou sofreu violência física, o que caracterizou a chamada resistência passiva (o ato de espernear ou bravejar contra policial, ao ser preso). Aqui, o caso é diverso, porque a ré efetivamente empregou violência física contra os policiais, como já acima apontado.

Assim, não resta dúvida de que, no dia, horário e local descritos na peça acusatória, a ré ELOÁ se opôs à execução de ato legal mediante violência física aos policiais militares Mauro Américo Barbosa Moreira Sanchez e Michel Ricardo Gomes. A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 329, caput, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do agente ou extinga a punibilidade.

Reconheço, pois, a ocorrência dos delitos e passo à aplicação das penas, separadamente.

Penas.

Resistência (Eloá).

A acusada não ostenta maus antecedentes e as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhes são favoráveis, autorizando a fixação da pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas.

Torno definitiva a pena em 02 (dois) meses de detenção.

Tráfico de Drogas (Eloá)

A ré não registra maus antecedentes, no entanto, nesta fase da aplicação da pena, deve ser levado em conta que a introdução da considerável quantidade de droga no mercado (nada menos do que 72,10 gramas de maconha e 99,12 gramas de cocaína), se fosse alcançada, traria efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-lo com a sanção base mínima, tratando-o igualmente, por exemplo, a quem fosse preso traficando algumas gramas daqueles entorpecentes.

Essa é a posição de nossos Tribunais:

“Na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa” (STJ, HC 13.231-MS, 5ª T., j. 22.08.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000 – RT 786/599).

“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena obedecerá aos critérios do art. 59 do CP entre eles os motivos, as circunstância e consequências do crime, razão pela qual se admite a fixação de pena-base acima do mínimo legal, se houve apreensão de grande quantidade de droga” (STJ, HC 11.235-SP, 5ª T., j. 16.03.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 17.04.2000, RT 783/594).

“Admissível, em tema de comércio clandestino de entorpecente, é a maior severidade na repreensão penal em face da natureza mais nociva ou da maior quantidade de substância tóxica apreendida” (TACRIM-SP-AC-Rel. Geraldo Pinheiro – JUTACRIM 44/293).

“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu

tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC - 687055624 - Rel. Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154)

PENA - Agravantes - Tráfico de entorpecentes - Associação - Hipótese em que, se a Justiça Pública houvesse apelado, caberia modificação no decreto condenatório, pois a grande quantidade de entorpecente apreendida justificaria plenamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, além de que o "modus operandi" do casal criminoso, demonstra organização que merecia maior rigor punitivo; todavia, como não é possível "reformatio in pejus", a pena cominada na r. sentença deve prevalecer - Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 1.044.309-3/5 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Marco Antonio - 23.8.2007 - V.U. - Voto n. 6.277)

Portanto, levando em conta o dado elencado, no aspecto acima relatado (quantidade da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três dias) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Não é caso de aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque, embora a ré não seja reincidente e não ostente maus antecedentes, restou demonstrado, por todos os elementos acima descritos, bem como pela apreensão de grande quantidade de drogas, de espécies diversas (sendo nada menos do que 72,10 gramas de maconha e 99,12 gramas de cocaína), que o acusado se dedicava à narcotraficância em escala expressiva, guardando droga em sua residência, de modo que é forçoso reconhecer que se dedicava a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida.

Neste sentido, já se decidiu:

" Sem incidência , porém, na última fase da dosagem, de retroativa redutora, por conta do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que, pese a primariedade e bons antecedentes, concretamente, a forma de embalagem da droga apreendida (cerca de sessenta e cinco invólucros), sua natureza (crack) e forma de ação desenvolvida - para fim de venda a indeterminado número de pessoas - antes de caracterizar eventual pequeno tráfico, traz indicações de fazer do fato modo de vida, exercício de atividade criminosa."

Em outros termos, a quantidade expressiva de entorpecente, inversamente ao princípio da insignificância, poderia causar consequências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte da acusada, já que realizava o tráfico em escala considerável, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade, razão pela qual não faz jus à redução em questão.

Observa-se que, diante dos diferenciados tipos de pena privativa de liberdade (reclusão e detenção), não poderá ser aplicado o concurso material com a soma das penas. Fixo, assim, cada pena separadamente, observando-se, na fase de execução, o disposto no artigo 69, caput, 2ª parte, do Código Penal.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Tráfico de drogas (Roberto)

O acusado ostenta mau antecedente (fls. 625/626 - Proc. nº 0014088-26.2011.8.26.0077), razão pela qual uma das circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhe são favoráveis, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo

legal. Afora isso, nesta fase da aplicação da pena, deve ser levado em conta a introdução da considerável quantidade de droga no mercado, tal qual exposto quanto à acusada Eloá.

Portanto, levando em conta o dado elencado, nos aspectos acima relatados (mau antecedente e quantidade da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância agravante da multirreincidência (fl. 624 - Proc. nº 0008617-87.2015.8.26.0077 e fl. 625 - Proc. 0013178-96.2011.8.26.0077) razão pela qual elevo a pena em mais 1/3 (um terço), resultando em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de aumento ou diminuição de pena. Não é caso de incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque o réu é reincidente e ostenta mau antecedente, o que afasta o benefício.

Ademais, ainda que assim não fosse, também não seria o caso de aplicação dessa causa de diminuição, pelos mesmos motivos expostos na terceira fase da aplicação da pena da ré Eloá.

Torno definitiva a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias e pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa.

Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (Réu Roberto).

Como acima já exposto, o réu ostenta mau antecedente (fls. 625/626 - Proc. nº 0014088-26.2011.8.26.0077), razão pela qual as circunstâncias do artigo 59 não lhe são favoráveis. Fixo, pois, a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da multirreincidência (fl. 624 - Proc. nº 0008617-87.2015.8.26.0077 e fl. 625 - Proc. 0013178-96.2011.8.26.0077), razão pela qual elevo a pena em mais 1/3 (um terço), resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Torno definitiva a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Reconheço o concurso material entre os delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, de modo que as penas desses crimes serão somadas, conforme dispõe o artigo 69 do Código Penal, resultando em 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 894 (oitocentos e noventa e quatro) dias-multa.

No que toca ao delito de resistência (ré Eloá), o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Referente aos crimes de tráfico de drogas (réus Roberto e Eloá) e posse ilegal de arma com numeração suprimida (réu Roberto), diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), as penas devem ser cumpridas no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, lembrando que o réu Roberto é reincidente específico.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dos acusados, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua

de informações concretas.

O acusado Roberto deverá continuar a responder preso por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Por sua vez, a acusada Eloá foi solta mediante liberdade provisória concedida na audiência de custódia e assim permaneceu durante a instrução, razão pela qual poderá continuar a responder ao processo em liberdade.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica dos réus.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

1) CONDENAR ELOÁ CASSIA DO CARMO, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07), e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e

2) CONDENAR ELOÁ CASSIA DO CARMO, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena de 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 329, caput, do Código Penal;

3) CONDENAR ROBERTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (resultado da soma das penas dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma com numeração suprimida), em regime inicial fechado, e pagamento de 894 (oitocentos e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, dando-o como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Consigno que o acusado Roberto ficou preso cautelarmente desde 16/05/2020 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contra-senso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição

prevista no artigo 44 do Código Penal, ou